

1501050-62.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... já conhecida pela ocorrência do tráfico de drogas e, em operação para coibir o crime de tráfico de entorpecentes, realizou campanha, momento em que visualizou o acusado sendo abordado por uma pessoa, tendo ambos iniciado breve diálogo. Relatou que viu o réu entregar algo ao indivíduo que dele havia se aproximado. Disse que, diante dessa dinâmica, foi realizada a abordagem, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501050-62.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501050-62.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUE PEREIRA DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

KAUÊ PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 333, caput, do Código Penal, ambos os delitos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", deste diploma legal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, cinco tiras de maconha e três pinos plásticos contendo esta mesma droga, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e espaço, o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, foi o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação para a condenação do réu, nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou pedidos relativos à fixação da pena e do regime prisional.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas e, especificamente, quanto ao delito de corrupção ativa, também em razão de atipicidade de conduta e por configurar-se crime impossível. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo pericial, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia.

Disse que faz uso de maconha e foi ao local dos fatos para adquirir a droga. Contou que parou no local e aguardou que o indivíduo que vendia a droga o servisse. Disse que entregou o dinheiro ao traficante para que ele buscasse a maconha e viu quando o veículo dos policiais chegou ao local. Alegou que o indivíduo então retornou e lhe entregou a maconha. Disse que um dos policiais depoentes aproximou-se correndo na direção do traficante, que fugiu, e então ambos os policiais o abordaram. Contou que estava com duas porções de maconha na mão e foi questionado sobre o que estava fazendo no local. Disse aos policiais que estava apenas comprando as drogas e os agentes queriam que identificasse o traficante, mas disse a eles que não o conhecia. Alegou que, ao chegar ao local dos fatos, não encontrou o traficante e, então, permaneceu na bicicleta. Disse que viu um veículo encostado e aguardou que o traficante se aproximasse para servi-lo de maconha. Contou que entregou R\$10,00 ao traficante e recebeu deles duas porções no valor de R\$5,00 cada. Não sabe a quantidade total de droga apreendida pelos policiais. Disse que não havia outras drogas consigo, além daquela que havia acabado de adquirir. Declarou não conhecer o indivíduo que estava realizando o tráfico. Alegou que foram os policiais que o questionaram sobre ter “ideia para trocar” ou se possuía algo a oferecer e disse aos policiais que tinha dinheiro, mas, na verdade, nada possuía. Contou que nada falou sobre valores. Disse que nenhum valor foi encontrado consigo, pois havia entregado o dinheiro ao traficante para adquirir as porções de maconha.

Contudo, a negativa do réu e a versão por ele fornecida, além de não serem críveis, não encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos.

A testemunha policial civil Edmilson Sena Amorim de Souza Costa, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que, em operação para combate ao tráfico de drogas no local onde ocorreram os fatos, para lá dirigiu-se com seu parceiro e realizaram campana em viatura descaracterizada. Narrou que visualizou o acusado parado próximo à Rua São Cristóvão com a Rua Haroldo de Camargo e viu quando outro indivíduo aproximou-se do acusado e conversou com ele. Declarou que viu o momento em que o réu entregou algo àquele indivíduo. Disse que, nesse momento, correu e conseguiu abordar o réu, enquanto o outro indivíduo obteve êxito em evadir-se. Relatou que com o acusado foram localizados cinco filetes de maconha e três eppendorfs contendo o mesmo entorpecente. Narrou que, dada voz de prisão, o réu ofereceu-lhe a quantia de R\$500,00, a fim de que ele fosse liberado, sem assumir sua responsabilidade pelo crime cometido. Esclareceu que o relógio onde consta a gravação do ocorrido era seu. Declarou que não conhecia o réu anteriormente aos fatos. Consignou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Relatou que a campana foi realizada por cerca de 20 minutos e, durante esse período, somente viu uma pessoa aproximar-se do réu, sendo um homem jovem e de estatura mediana, cuja vestimenta não se recordou. Esclareceu que, ao desembarcar da viatura para realizar a abordagem, que estava a cerca de 15 a 20 metros do local dos fatos, o indivíduo que havia se aproximado do réu viu a equipe policial e saiu correndo, não sendo possível sua abordagem. Consignou que a droga foi localizada dentro de um maço de cigarro que estava na cintura do réu. Afirmou que, da distância em que estava realizando o monitoramento, era possível distinguir com clareza quem estava

realizando o tráfico de drogas e quem aproximou-se para adquirir a droga. Relatou que o dinheiro foi oferecido para si e seu parceiro de ofício, o que ocorreu tanto no local dos fatos quanto dentro da viatura, no caminho para a delegacia. No mesmo sentido, a testemunha policial civil Diego Parada Lopes, ouvida em Juízo, narrou que o local dos fatos situa-se em região já conhecida pela ocorrência do tráfico de drogas e, em operação para coibir o crime de tráfico de entorpecentes, realizou campana, momento em que visualizou o acusado sendo abordado por uma pessoa, tendo ambos iniciado breve diálogo. Relatou que viu o réu entregar algo ao indivíduo que dele havia se aproximado. Disse que, diante dessa dinâmica, foi realizada a abordagem, que foi exitosa somente em relação ao réu, pois o outro indivíduo conseguiu evadir-se. Declarou que, na cintura do réu, foi encontrado um maço de cigarro contendo maconha, em oito porções. Narrou que, ao ser colocado na viatura para ser conduzido à delegacia, o acusado ofereceu uma quantia em dinheiro, cujo valor não se recordou, a fim de que ele fosse liberado, admitindo, informalmente, a prática do tráfico de drogas. Consignou que a expressão “cinco pernas” refere-se ao valor de R\$500,00. Relatou que a campana foi realizada do lado oposto da rua onde estava o acusado e não havia nenhum obstáculo que impedisse a visualização dos fatos. Esclareceu que a gravação constante dos autos, em que foi registrado o oferecimento de dinheiro pelo réu, foi feita com o uso do relógio que estava com seu parceiro de ofício. Declarou que não conhecia o réu anteriormente aos fatos. Relatou que, na semana em que ocorreram os fatos, estava ocorrendo operação para combate ao tráfico de drogas e narrou que, no dia a dia, há operações visando coibir determinados crimes. Esclareceu que, durante a campana, que não foi longa, viu o réu de bicicleta, na calçada, fazendo pequenos deslocamentos de um lado a outro, viu quando um indivíduo aproximou-se do réu e viu o momento em que o acusado entregou algo àquele indivíduo, sendo, nesse momento, tomada a decisão de abordagem. Consignou que não pode ver qual foi o objeto que o réu entregou ao outro indivíduo, que conseguiu evadir-se, enquanto o réu acabou por ser abordado. Não recordou de ter encontrado dinheiro com o acusado. Esclareceu que o réu, ao ser detido, demonstrava apenas nervosismo diante de sua prisão. Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas. Ressalta-se a palavra dos policiais civis, que de maneira segura, uniforme e convincente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem do acusado e a apreensão da droga. Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos dos policiais. Como já se decidiu “é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade” (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se “imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento” (TJSP – AP – Rel. Walter Guilherme – j. 10.03.98 – JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: “Tóxicos -

Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2ª T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Mm. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais,

mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa.

Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Cezar Peluso – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Luiz Fux – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes – Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes – Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor – Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se

prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de comprovação de nexo causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino – Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva – Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva.” (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a):

Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

Apenas para consignar, o esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais não é suficiente para retirar a força probante deles.

As acusações contra os policiais civis que participaram da prisão em flagrante do réu não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório.

Argumentos genéricos que visam a desprestigiar a Polícia como um todo em nada influenciam na prova colhida no presente caso.

Frise-se que os depoimentos das testemunhas, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a localização dos entorpecentes, além de estarem em verdadeira consonância com suas declarações prestadas à Autoridade Policial.

Ambas as testemunhas afirmaram que, durante campana em local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, avistaram o acusado, inicialmente sozinho, e, então, viram um indivíduo dele aproximar-se.

Narraram que viram o réu entregar algo ao terceiro que dele aproximou-se e ressaltaram que, diante da conduta que estavam presenciando, decidiram realizar a abordagem.

Consignaram que, no momento da abordagem, o indivíduo que havia procurado o acusado conseguiu evadir-se, tendo a equipe policial obtido êxito na contenção do réu, com quem localizaram, durante a busca pessoal, cinco porções de maconha em filetes e três porções de maconha em cápsulas, que estavam em um maço de cigarro em sua cintura.

Por fim, narraram que o acusado ofereceu a eles uma quantia em dinheiro, a fim de que não o conduzissem à delegacia, evitando assim sua responsabilização penal, o que foi registrado por áudio feito com o auxílio do relógio portado pela testemunha Edmilson.

Veja-se que, embora não tenha sido encontrada quantia em dinheiro com o acusado, esta circunstância não retira a validade dos depoimentos dos policiais civis quanto à identificação do réu como o indivíduo que estava praticando o tráfico de drogas. Repise-se que as testemunhas consignaram ter sido o réu a pessoa que inicialmente foi vista por eles no local já conhecido como ponto de tráfico de drogas e que foi ele a pessoa procurada por um terceiro, bem como que foi ele quem fez a entrega de algo ao terceiro.

Ainda, depreende-se de seus depoimentos que, ao verem a movimentação típica do tráfico de drogas, deslocaram-se no sentido do réu e do indivíduo que o havia procurado, sendo que este último conseguiu evadir-se.

Assim, conforme a dinâmica descrita pelos policiais, de onde se infere a tentativa de abordagem no momento da mercancia ilícita, nem mesmo é possível afirmar-se que tenha havido tempo hábil para que o pagamento da droga pelo usuário fosse realizado.

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, não há dúvidas de que era o acusado era

o indivíduo que estava realizando o tráfico de drogas no local dos fatos. De outro lado, nenhuma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa foi trazida em Juízo para ser ouvida, a fim de esclarecer os fatos ou, ao menos, contrariar concretamente a versão apresentada pelas testemunhas policiais civis.

Assim, a negativa do réu e a versão por ele apresentada - de que foi ao ponto de tráfico para comprar drogas e que lá ficou aguardando para ser atendido pelo traficante que sequer estava no local e que, este, sim, o procurou para vender as drogas - não se mostraram críveis e restaram absolutamente isoladas do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo acusado sobreponha-se aos depoimentos dos agentes de segurança encarregados de sua prisão, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos dos policiais civis, que sequer conheciam o réu anteriormente aos fatos, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu é de fato traficante.

No presente caso os elementos de convicção são contundentes, seja em virtude da quantidade das drogas apreendidas, seja pela ação da equipe de policiais, tudo aliado à negativa isolada do réu.

Apenas para consignar, não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do acusado deriva da quantidade de drogas e demais circunstâncias em que elas foram apreendidas. De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - AC 1.327/92 - Rel. Adolphino A. Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

O crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal também restou suficientemente demonstrado.

Há prova suficiente nos autos acerca da materialidade e de sua autoria.

As testemunhas policiais civis relataram de forma uníssona como se deu o oferecimento, pelo acusado, de uma quantia em dinheiro a fim de não ser detido.

Os depoimentos dos agentes de segurança devem ser admitidos como subsídio de persuasão do juiz, já que o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular, conforme já pacificado na doutrina e jurisprudência, precipuamente nos casos de crime de corrupção ativa, em que a consumação da prática delitiva, via de regra, ocorre apenas na presença do agente e do funcionário a quem foi oferecida a gratificação.

Porém, observe-se que, no presente caso, há também registro em áudio, feito pelo policial civil Edmilson, do momento em que o acusado oferece o dinheiro à equipe policial, para escapar à sua responsabilização penal.

Saliente-se que o conteúdo da mídia, que pode ser acessada por QRcode às fls. 18 confirma os relatos apresentados pelas testemunhas policiais, não havendo, portanto, qualquer dúvida sobre o delito e sua autoria.

Quanto à licitude da gravação realizada, veja-se:

"GRAVAÇÃO AMBIENTAL - INTERLOCUTOR - PROVA - VALIDADE. É válida a utilização de gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, como meio de prova no processo penal - recurso extraordinário nº 583.937, relator ministro Cezar Peluso, julgado sob o regime da repercussão geral. Ressalva de entendimento pessoal. PROVA - PRODUÇÃO - INDEFERIMENTO. O artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal versa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente." (RHC 112428, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)

"EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos

interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro." (RE 583937 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01741 RTJ VOL-00220-01 PP-00589 RJSP v. 58, n. 393, 2010, p. 181-194)

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. GRAVAÇÃO DE CONVERSA PELO INTERLOCUTOR. PROVA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE. DESRESPEITO À INTIMIDADE INEXISTENTE.

1. A uníssona jurisprudência desta Corte, em perfeita consonância com a do Pretório Excelso, firmou o entendimento de que a gravação efetuada pela vítima dos fatos, em tese, criminosos, é prova lícita, que pode servir de elemento probatório para a notitia criminis e para a persecução criminal.

2. Ademais, trata-se de gravação de funcionários públicos no exercício de sua função pública, e não de conversa particular ou sigilosa, o que afasta a incidência do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, que garante a intimidade da vida privada.

3. Recurso desprovido." (RHC n. 14.672/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/6/2005, DJ de 29/8/2005, p. 367.)

Quanto ao elemento subjetivo, o crime de corrupção ativa exige, além do dolo genérico, consistente na vontade de oferecer ou prometer a vantagem, o elemento subjetivo do tipo (dolo específico, para a doutrina tradicional), referente ao especial fim de agir do agente (para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício).

No caso em tela, não restam dúvidas de que o acusado, ao oferecer dinheiro aos policiais militares para que estes deixassem de cumprir seu dever de ofício, ciente de estar oferecendo uma vantagem indevida, agiu de forma livre e consciente para a consecução do delito, tendo domínio do fato e sabedoria sobre a contrariedade à ordem jurídica.

Finalmente, infere-se da prova produzida nos autos que o oferecimento da vantagem indevida ocorreu antes de ser o acusado ser apresentado à Autoridade Policial que lavraria o auto de prisão em flagrante, não prosperando, assim, a tese de atipicidade arguida pela Defesa.

Provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, e provada, também, a materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa, a condenação do réu é medida que se impõe.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado não é portador de maus antecedentes e não há outras razões para a elevação de sua pena-base acima do mínimo legal, que fixa fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o réu é reincidente pela prática de mesma espécie de delito, conforme certidão criminal de fls. 23, motivo pelo qual aumento sua pena em 1/3, a qual resta fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor já estabelecido.

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública.

Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não

a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime.

Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. A pena deve ser acrescida de 1/6, ficando fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor já estipulado.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento de pena a serem reconhecidas e não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da reincidência específica do acusado. Com efeito, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização dos maus antecedentes ou reincidência para o aumento da pena nas primeiras fases da dosimetria e, ainda, suas considerações para fins de afastamento da redutora prevista na Lei de Drogas, posto que tal conjuntura, na primeira e segunda em relação à terceira etapa de dosagem das penas, possui natureza jurídica diversa. Neste sentido, já decidiu o Pretório Excelso, confira-se:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO. IDONEIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes ostentados pelo réu e a natureza altamente nociva da droga apreendida, de modo que a reprimenda não merece nenhum reparo nesse ponto. II Não procede a alegação de que a inexistência de certidão cartorária atestando o trânsito em julgado de eventual condenação inviabilizaria o reconhecimento de maus antecedentes/reincidência e que a folha de antecedentes criminais não serviria para esse fim. Esta Corte já firmou entendimento no sentido da idoneidade do referido documento, que possui fé pública. Precedentes. III Infração cometida em transporte público. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006. IV Não caracteriza bis in idem a consideração da reincidência para fins de majoração da pena-base e como fundamento para a negativa de concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. V- Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. VI Réu que apresenta maus antecedentes, condição que impede a aplicação da referida causa de diminuição. VII - Ordem denegada. (HC 107274, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 12/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 19-04-2011 PUBLIC 25-04-2011 LEXSTF v. 33, n. 388, 2011, p. 367-376).

Ainda no mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. "1. Constatando-se que a paciente ostenta maus antecedentes, ausente ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não preenchimento de exigência determinada nesta regra. "2. As circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante da agente, somadas à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida em seu poder - mais de 3 quilos de maconha -, ademais, levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, dedicando-se a atividade criminosa..." (STJ HC 230.835/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 21/09/2012).

Quanto ao crime de corrupção ativa, atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado não é portador de maus antecedentes e não há outras razões para a elevação de sua pena-base acima do

mínimo legal, que fixa fixada em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o réu é reincidente, conforme certidão criminal de fls. 23, motivo pelo qual aumento sua pena em 1/6, a qual resta fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor já estabelecido.

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública, na forma como já exposto, impondo-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em 1/6, ficando fixada em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor já estipulado.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material, devem as penas ser somadas, o que resulta na pena final de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, no valor já fixado.

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, praticado em concurso material com o delito de corrupção ativa, e diante da reincidência específica do acusado quanto ao crime de tráfico de drogas, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)
Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu KAUÊ PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e

ao pagamento de 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 333, caput, do Código Penal, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, e em concurso material, na forma do artigo 69 deste mesmo diploma legal. Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social, além de ser o acusado reincidente específico por este delito. A reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social. Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição. Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Custas na forma da lei. P.R.I.C. São Vicente, 13 de julho de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA